

1500163-34.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... de prova: 'Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova Depoimentos de policiais Indícios e circunstâncias que convencem da autoria Condenação mantida (...).Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico' (Apelação Criminal n., de São José, rel. Des. Amaral e Silva , j. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500163-34.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500163-34.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON DIAS LIMA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra EMERSON DIAS LIMA DA SILVA, qualificado a fl. 8, imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c.c art. 29, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta de 01h10, no estabelecimento comercial situado na Avenida Brasil, nº 1201, centro, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, o DENUNCIADO, mediante rompimento de obstáculo e durante o período de repouso noturno, em concurso de pessoas com terceiro não identificado, subtraíram, para eles, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, ano 2007,

cor prata, placa DTL 9465 – Presidente Prudente/SP, consoante auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 45/46 e auto de avaliação de fls. 99/100, em prejuízo da vítima Luiz Eduardo Fioramonte Serrano. Ao que consta, no dia dos fatos o denunciado, juntamente com seu comparsa de alcunha “Cicatriz”, se dirigiu ao estabelecimento comercial situado no local supra com a finalidade de subtrair bens para posteriormente os revenderem. Assim, aproveitando o período noturno e, portanto, da ausência de pessoas no local e nas proximidades, colocaram em prática o plano delituoso. “Cicatriz” jogou uma pedra contra uma porta de vidro, quebrando-a, e adentraram o local. Em seguida, subtraíram a motocicleta e deixaram a loja, pilotando-a. Contudo, o alarme de segurança soou e a polícia, bem como o proprietário do estabelecimento foram acionados. Policiais Militares que realizavam patrulhamento de rotina avistaram dois rapazes em uma motocicleta em alta velocidade pela Rua Mendes de Moraes e emitiram sinal de parada. Por outro lado, os investigados, ao avistarem a polícia, jogaram a moto no chão e se evadiram. O DENUNCIADO foi preso em flagrante e “Cicatriz” ainda não fora identificado e localizado. A motocicleta foi avaliada em R\$ 6.646,00 (seis mil, seiscentos e quarenta e seus reais – fls. 99/100). O objeto foi restituído à vítima (fls. 45/46).”. Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

A denúncia foi recebida pelo despacho de fls. 112/113, de 24 de fevereiro de 2022, tendo o réu após regular citação ofertada defesa preliminar (fls. 125/126), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 129) e o despacho de fls. 131/135, de 19 de abril de 2022, confirmou o recebimento da denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 175/176) pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia, ante a prova dos autos. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor (fls. 175/176), pediu, em resumo, absolvição do réu, ante a absoluta ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Superada tal tese, em caso de eventual condenação, requer o não reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno, já que o crime foi cometido em estabelecimento comercial, e que seja fixado regime diverso do fechado, levando em consideração o tempo de prisão provisória para estabelecimento do regime inicial, bem como vem rechaçar o pedido do Ministério Público para indenização dos danos à vítima, vez que não há prova nos autos dos danos efetivos, podendo a vítima se socorrer da esfera civil para reparação dos danos.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade do delito narrado na denúncia e imputado ao réu encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 45/46, pelo auto de avaliação de fls. 99/100; pelo laudo pericial de local de fls. 167/174; bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em Juízo, a vítima Luis Eduardo Fioramonte Serrano, declarou que estava em sua residência quando tocou o alarme da loja em seu celular. Foi até o local já encontrando cheio de viatura, tendo um dos policiais lhe disse já ter prendido o autor do furto. Teve danos, o autor quebrou o vidro da porta da fachada e o prejuízo ficou em torno de R\$ 650,00 e com a moto, gastou mais R\$ 200,00 em razão de ele ter derrubado a moto no chão. No estabelecimento existe câmeras de segurança on line e gravou toda a ação da subtração, e não possui mais as gravações porque após sete dias é gravado por cima das gravações anteriores.

A testemunha PM. Nilton Cesar Gasparini da Silva, sob o crivo do contraditório,

declarou que foi radiada via copom a subtração na loja de que havia sido furtada uma motocicleta de cor cinza, e em patrulhamento nas imediações, visualizaram a motocicleta com dois indivíduos e ao dar sinais luminosos e sonoros, empreenderam fuga pela 1º de maio sentido a linha férrea, momento em que pararam e cada um para um lado, sendo possível deter apenas um deles. Indagado acerca da subtração, o autuado disse que foi seu parceiro que estourou a porta de vidro para furtarem a moto, uma pessoa com vulgo de "Cicatriz". Quando o avistou, eles estavam na Rua João Elias Naufal, uns 3 quarteirões da linha férrea. Afirma que se depararam com eles de frente, e aproximadamente uns dois metros da viatura que eles passaram, então retornaram e passaram a perseguir a motocicleta até abordá-los. Após eles deixarem a moto, o Emerson estava há aproximadamente três ou quatro metros da motocicleta, porque ele empreendeu fuga, não conseguindo subir no barranco próximo. Afirma que foi o Emerson que deixou a motocicleta e tentou fugir, pois quando eles jogaram a motocicleta, um policial foi atrás de um enquanto ficou para ir atrás de Emerson.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

"PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))".

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que "como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" - "Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))"

Observe-se que o depoimento dos policiais foi unânime, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que "o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento" (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O

só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que "pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis" (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278).

Em seu interrogatório, o acusado Emerson Dias Lima da Silva, declarou que já foi preso e cumpriu pena anteriormente. Sobre os fatos disse que não cometeu o delito. Estava na linha do trem, local de usuário de drogas e também usava drogas, quando passou esses dois rapazes na moto, não estava na moto, deixaram a moto perto, há uns 10 metros de onde estava, quando apareceu a viatura, virou a esquina, lhe abordaram, lhe pressionaram e disseram que teria furtado a loja, e perguntaram se tinha passagem, o acusaram por já ter passagem. Afirmo que não furtou a loja, nem sabe qual estabelecimento, estava na linha do trem usando droga com outros vários usuários.

Perante a Autoridade Policial, o réu Emerson Dias Lima da Silva declarou que na madrugada de hoje, junto com um amigo de apelido "Cicatriz", jogaram uma pedra em uma porta de vidro de uma loja na Avenida Brasil e furtou uma moto de lá, sendo que pretendiam vender a moto e fazer um dinheiro. Acontece que foi preso logo em seguida por militares, "Cicatriz" conseguiu fugir.

No caso, estando a confissão informal em consonância com os demais elementos de convicção, consoante apontado, também ostenta valor probatório. Nesse sentido: A respeito da figura da confissão informal, reproduz-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: "O detido poderá dar depoimentos aos policiais na sua casa, no lugar onde foi preso ou mesmo no interior da viatura a caminho da delegacia e essas declarações lhe serão perniciosas no futuro. Não é raro que policiais sejam arrolados como testemunhas de acusação, não do fato delituoso, mas para que contem, em juízo, o que ouviram do réu quando este foi preso. Por certo que tal admissão de culpa, feita fora da delegacia, não é uma confissão, no sentido jurídico do termo, mas não deixa de ser um importante elemento de prova, constituído, afinal, pelos testemunhos daqueles que a ouviram" (O Valor da Confissão como Meio de Prova no Processo Penal 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 230). A jurisprudência deste Sodalício já consagrou a possibilidade da utilização da confissão informal como relevante elemento de prova: 'Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova Depoimentos de policiais Indícios e circunstâncias que convencem da autoria Condenação mantida (...).Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico' (Apelação Criminal n., de São José, rel. Des. Amaral e Silva, j. Em 8/1/2009)." (em TJSP, Apelação n. 0028006-47.2013.8.26.0071, rel. Des. Paulo Rossi, j. 03/02/2016).

"É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil."(TJSP, Apelação n. 9230875-35.2008.8.26.0000, rel. Silmar Fernandes, j. 10/05/2012).

Assim, ao contrário do afirmado pela defesa em sede de alegações finais nos autos há prova suficiente e segura a demonstrar não só a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, mas também a autoria deles pelo réu e de que inexistente qualquer causa que possa levar a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, entretanto, há importantes considerações a se fazer.

E os demais elementos de prova dos autos confirmam a confissão do réu, aliás, foi preso pelos Policiais Militares logo após ter sido perseguido e preso na posse do veículo furtado, confessando seu crime imediatamente.

A res furtiva foi localizada em poder do réu.

Em se tratando de crime patrimonial, a posse da "res" inverte o ônus da prova, vez que:

"Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado

gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia é inverossímil transmuda a suposição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório." (RJDTAcrim - volume 1, janeiro/março 1989, pag.103 - Rel. S. Braz).

"Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída, em poder do agente autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-se a justificativa inequívoca, de modo que explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório." (TACRIM-SP - AC - Rel. Norberto Mortari - RJD 18/47).

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RESISTÊNCIA A PRISÃO. PROVA. POSSE DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ERRO MATERIAL. Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, o que, aliado ao reconhecimento seguro da vítima, autoriza o decreto condenatório. A pena-base deve buscar um patamar proporcional às ações delitivas e ajusta respotado Estado à violação de norma penal, não devendo situar-se no máximo e nem no mínimo cominado para o crime, se parte das circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu. Corrige-se, de ofício, o erro material contido no dispositivo." (Apelação nº 0007003-18.2013.8.22.0501, 2ª Câmara Criminal do TJRO, Rel. Daniel Ribeiro Lagos. j. 11.09.2013, unânime, DJe 18.09.2013).

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. RECEPÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA AO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE MANTEVE A COMPENSAÇÃO PARCIAL, ANTE A DUPLA REINCIDENCIADO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.-O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.-É entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícito bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal (HC 360.590/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017). (HC 385.130/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 23/05/2017). Fica latente nos autos, e elemento volitivo da ação, onde aproveitou-se da ausência de vigilância no local, e no momento oportuno, com animus de assenhoreamento de coisas alheias móveis, que sabia não lhe pertencer, portanto, o dolo fica comprovado diante da robustez das provas carreadas aos autos.

A qualificadora do rompimento de obstáculo restou incontestada, pelo laudo pericial de fls. 167/174, onde descreve que "Danos, de aspecto recente, constituídos de amolgamentos e desalinhos da estrutura metálica próximo a região da fechadura; Ruptura total, de uma das folhas de vidro móveis; Atritos e impregnações de sujidades acinzentadas, na face externa do vidro; Fragmentos de vidro temperado, no chão, nas proximidades da porta (região interna e externa); Fragmentos de pedra e 1 (um) retrovisor de motocicleta, sobre o passeio público, próximo a região da porta violada. Conclui-se que o ingresso do(s) autor(es) ao interior do estabelecimento comercial ocorreu mediante rompimento de obstáculo, através da porta de vidro, localizada na porção direita, frontalmente à edificação. Aparentemente, os danos constatados na estrutura metálica, da porta arrombada foram produzidos por instrumento à guisa de alavanca associado à força muscular, com orientação de fora para dentro. Enquanto que a ruptura do vidro, eram coerentes com uma ação intencional, onde os danos constatados foram resultantes de uma força de ação contundente, provavelmente ocasionados com a força muscular e/ou objetos. Não se descarta o uso de pedra(s), nas quais, os fragmentos foram observados no passeio público.", bem como pela prova produzida em Juízo.

Como visto, os elementos acima salientados são provas e indícios claros que

traduzem a certeza de que o acusado praticou o crime descrito na denúncia e que tinha a intenção de subtração.

Comprovado exhaustivamente, que o réu também estava acompanhado de seu comparsa, pessoa de vulgo "Cicatriz", que não foi possível a sua prisão em razão de ter sido possível alcança-lo, após ter se livrado do veículo, embora tenha sido perseguido pelo Policial Militar Jonathan Vieira.

Nesta diretriz: "Qualifica o crime de furto ter sido ele praticado mediante o concurso de duas ou mais pessoas, o que denota maior periculosidade dos concorrentes. Não exigindo a lei que o crime seja executado por duas ou mais pessoas, configura-se a qualificadora mesmo que, havendo partícipe, a fase executiva fique a cargo de apenas uma pessoa" (Código penal interpretado/Julio Fabbrini Mirabete/Renato N. Fabbrini, 6. ed., 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 2007). Quanto ao crime ter sido cometido durante o período de repouso noturno, como prescreve o artigo 155, §1º, do Código Penal, restou indubitavelmente comprovado nos autos.

É que a referida causa de aumento de pena foi criada pelo legislador para tutelar o patrimônio alheio em período de maior vulnerabilidade de sua vigilância, não importando se o local está, ou não, habitado, se é destinado à residência ou à atividade comercial, se é de natureza móvel ou imóvel, bem como se eventual morador está ou não, efetivamente, repousando.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência colacionada a seguir: "Ementa: RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal incide na hipótese de furto praticado em estabelecimento comercial no período do repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração. Precedentes. 2. Recurso especial provido."(STJ - RECURSO ESPECIAL Resp 1193074 MG 2010/0084033-3

(STJ) Data de publicação:15/03/2013)."PENAL.FURTOS CIRCUNSTANCIADOS. REPOUSO NOTURNO. CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO.

DESPROVIMENTO. 1. Materialidade e autoria confirmadas pelo conjunto probatório. 2. A causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CP foi criada pelo legislador para tutelar o patrimônio alheio em horário em que se presume maior vulnerabilidade da sua vigilância. Não importa se o local está, ou não, habitado, se é destinado a residência ou a atividade comercial ou, ainda, se é de natureza móvel ou imóvel. Também é irrelevante se a vítima está no local repousando. Precedentes deste TJDF e do STJ. 3. Ausente o requisito subjetivo, unidade de

desígnio, rejeita-se a tese de continuidade delitiva, ainda que presentes os requisitos objetivos, a proximidade temporal e a dos locais dos delitos e a semelhança na execução. 4. Apelação desprovida." (Classe do Processo:

20110810062074APR - (0006054-06.2011.8.07.0008 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 664399, Data de Julgamento: 21/03/2013, Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: GEORGE LOPES LEITE, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 01/04/2013. Pág.: 16).

Ademais, em se tratando de repouso noturno, a presença ou não de pessoa no local, dormindo ou despertas, em estabelecimento comercial ou residência desabitada, não se revela acertada acolher, já que o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu, que independe de estar habitado e tenha pessoas no local, bem como ser um estabelecimento comercial, presente esta a causa de aumento de pena, senão vejamos a mais recente decisão acerca do tema:

"HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ABUSO DE CONFIANÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CRITÉRIO OBJETIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. QUALIFICADORA RELATIVA AO ABUSO DE CONFIANÇA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. NATUREZA SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 511/STJ. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO. 1. No julgamento do HC 628.647/SC em 9/3/2021, a Sexta Turma, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da

Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio *tempus regit actum* em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. 2. Denunciados e, ao final condenados, pela prática do crime de furto qualificado, com pena mínima de 2 anos de reclusão, não se mostram presentes os requisitos legais previstos no art. 89 da Lei 9.099/05 para a aplicação da suspensão condicional do processo. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. 4. A teor da Súmula 511 do STJ, "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva." Em se tratando de condenação por furto qualificado pelo abuso de confiança, cuja natureza é subjetiva, não incide o privilégio, a despeito da primariedade do apenado Paulo Henrique Pereira e do do valor do bem subtraído. 5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto (apenado Jairo de Souza), a despeito de a pena final ser inferior à 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 6. Habeas corpus denegado. (HC 615.113/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). Por fim, pleiteia o Ministério Público a fixação de indenização dos danos à vítima pelo réu, tendo em vista que suportou prejuízos na reparação da porta de vidro e na motocicleta, pois derrubaram a moto, causando danos. A princípio, não se tem nos autos informações acerca da avaliação dos prejuízos suportados, nem a própria vítima comprovou documentalmente os danos, importância para a apuração dos valores informados.

Nesse passo, cumpre consignar que não foi fixado nenhum valor para a reparação dos danos na peça acusatória, de tal forma que impede a outra parte conhecer e se manifestar, ainda que seja em conformidade com o valor apurado, ou ainda apresentar uma contraproposta, que se daria em uma fase de instrução específica para discussão do valor do dano *ex-delicto*, que mormente, deve existir um parâmetro objetivo para tal pedido, ou seja, uma avaliação dos prejuízos.

A jurisprudência nesse sentido é majoritária, senão vejamos:

"APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E AGENTE REINCENTE. PENA-BASE. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO DANO. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DA PENA E EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS CIVIS, AMBOS DE OFÍCIO. (TJ-PR - APL: 11985110 PR 1198511-0 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 03/07/2014, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1376 23/07/2014).

Assim, no caso em análise, verifico que esta questão não foi satisfatoriamente debatida na instrução, pois, embora o Ministério Público tenha requerido a indenização à vítima, não se dignou a produzir provas dos alegados danos ao longo da instrução.

É nesse sentido insta trazer à colação o excelente magistério de Guilherme de Souza Nucci: "É fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa"(Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a. Ed., 2009, p. 700).

Ademais, inexistindo instrução exauriente sobre os alegados prejuízos suportados

pela vítima, causados pela conduta do réu, em franca ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, não há como acolher o pedido de condenação a reparação de danos, devendo a vítima, caso tenha interesse, pleitear a devida indenização na esfera cível.

Necessário não perder de vista a posição que a jurisprudência pátria vem assumindo diante da matéria, conforme ementa transcrita:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ, HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018. 2. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 3. Na hipótese, verifica-se dos autos que a autoria delitiva a respeito do crime de roubo na modalidade tentada não tem, ao contrário do alegado, como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Ademais, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após detida análise dos fatos e das provas - em especial os depoimentos dos policiais que surpreenderam o paciente, poucas horas após o crime, que havia dispensado um simulacro de arma de fogo, e do depoimento da própria vítima -, entendeu pela condenação do réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 4. Segundo o entendimento da Quinta Turma deste STJ, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp 1952768/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021). 5. Apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de reparação dos danos à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica acerca da questão, o que afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do paciente ao pagamento de indenização, sem instrução processual específica, implica cerceamento de sua defesa. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar da condenação o valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados à vítima, mantidos os demais termos da condenação." (HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021); e no julgamento:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE

VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PEDIDO NA DENÚNCIA, COM INDICAÇÃO DA QUANTIA PRETENDIDA, E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA A ESSE RESPEITO. ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento da Quinta Turma deste STJ, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1952768/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021); e ainda, "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. Precedentes. II - A tese fixada por esta eg. Corte de Justiça no sentido de que: 'Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.' (REsp 1675874/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 08/03/2018, grifei), não é aplicável ao caso, se tratando de delito de roubo. Agravo desprovido". (AgRg no RESp 1813825/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). Portanto, de rigor, a condenação do réu nos termos da denúncia. Passo a dosagem da pena.

A Folha de Antecedentes Criminais e a Certidão Estadual de Distribuidor de Processos de fls. 50/80, demonstra que é o réu reincidente específico, posto que anteriormente condenado por furto qualificado a pena de prisão, bem como já respondeu a outros vários processos, muitos deles por crimes contra o patrimônio, e para que seja considerado mau antecedente conforme consta a fls. 52 (Foro de Diadema - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0017403-07.2015.8.26.0050 (0003786-47.2018.8.26.0996) Situação: Suspenso. 19/05/2017 Sentença Condenatória (Art. 155 "caput" do(a) CP; Reclusão: um ano e três meses; Regime: Fechado; Multa de 12 dias. Valor da multa R\$ 315,20;) 26/05/2017 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 31/05/2017 Trânsito em Julgado para a Defesa (Sentença Condenatória) 18/10/2017 Prisão (Tipo de prisão: Sentença Definitiva; Local de prisão: Penitenciária Compacta de Tupi Paulista) 03/04/2018 Processo de Execução Iniciado (Processo atual: 0003786-47.2018.8.26.0996) além de tantos outros processo que já respondeu, portanto, levo em consideração as condições legais do artigo 59, do Código Penal, principalmente pelos maus antecedentes do réu, assim, fixo a pena base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto) pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda etapa, pela agravante genérica da reincidência específica (fls. 54 - Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 1500560-98.2019.8.26.0583 (0002647-89.2020.8.26.0996) Situação: Suspenso. 04/02/2020 Sentença Condenatória (Art. 155 § 4º, I c/c Art. 14, II ambos do(a) CP; Reclusão: um ano, cinco meses e dois dias; Regime: Fechado; Multa de 6 dias. Valor da multa R\$ 199,60;) 17/02/2020 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 17/02/2020 Recurso Interposto 09/03/2020 Processo de Execução Iniciado (Processo atual: 0002647-89.2020.8.26.0996) 10/07/2020 Acórdão - Sentença Reformada/Condenação (Art. 155 § 4º, I c/c Art. 14, II ambos do(a) CP; Reclusão: um ano e treze dias; Regime: Aberto; Multa de 4 dias. Valor da multa R\$ 133,07; Situação: Réu primário;) 30/07/2020 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Reformada/Condenação) 14/08/2020 Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Reformada/Condenação) 15/12/2020 Início da

Execução da Pena de Multa (Ex. Pena Multa nº 1024544-49.2020.8.26.0482) 10/03/2021
Pena Cumprida) aumento a pena de 1/6 (um sexto) e pela qualificadora do concurso de pessoas, conforme dispõe o artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, promovo o aumento de mais 1/6 (um sexto), esta, compenso com a atenuante da confissão espontânea em Juízo, conforme dispõe o artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal, aumento a pena em mais 1/3 (um terço), tornando a pena definitiva em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e multa de valor correspondente a 16 (dezesseis) dias multa, cada dia no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Impossível a substituição da pena corporal acima fixada por pena restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena por ser o réu reincidente específico e possuidor de maus antecedentes.

Ante a qualidade de reclusão da pena corporal e a condição de reincidente e possuidor de péssimos antecedentes criminais do réu, inclusive já cumpriu pena pelo mesmo crime, iniciará ele, o cumprimento da pena corporal em regime fechado.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu EMERSON DIAS LIMA DA SILVA, RG: 33867885, nascido em 13/05/1981, natural de São Paulo - SP, filho de MARCO ANTONIO LIMA DA SILVA e MARIA JORGINA DIAS DA SILVA, a cumprir a pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, e multa de valor correspondente a 16 (dezesseis) dias multa, cada dia no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, por violação as normas do artigo 155, § 4º, inciso I e IV, e artigo 155, §1º, c/c artigo 29, todos do Código Penal.

Ainda presentes os motivos da conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia e porque o réu respondeu todo o processo preso, agora, imponho-lhe a obrigação de recolher-se a prisão para poder apelar desta sentença. Incontinentemente, comunique-se a sentença no presídio que o réu se encontrar.

Quando da execução as multa deverão ser corrigidas monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA